

1500259-77.2022.8.26.0024

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... o réu por outros crimes, salvo engano tráfico de drogas. Disse que não se recorda se o réu foi comunicado de seu direito de ficar em silêncio. Aparentemente o réu estava tranquilo.

Interrogado, o réu confessou os fatos, dizendo que iria vender as barras de ferro para comprar drogas e cigarro.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500259-77.2022.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500259-77.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041225/2022 - DEL.SEC.ANDRADINA, 22989729 -

DEL.SEC.ANDRADINA, 2041225 - DEL.POL.CASTILHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS

Réu Preso

O Ministério Público ofereceu denúncia contra ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS imputando-lhe a prática do crime de furto simples (Art. 155 § 1º do CP).

Narra a denúncia que no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 22h30min, na Rua José Leandro de Souza, nº 1, Centro, na cidade de Castilho, nesta comarca de Andradina, o réu, qualificado às fls.10 e 12/14 dos presentes autos, subtraiu para si três barras de ferro, avaliadas em R\$ 180,00 (cf. auto de fls.16), pertencentes a Mykon de Araújo Santos.

A denúncia foi recebida em 04 março de 2022 em decisão de fl. 91. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.102/108.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a consideração das provas como ilícitas, por ausência de comunicação ao réu de seu direito ao silêncio pelos policiais militares (HC 203.163 do C. STF), aplicação do princípio da insignificância, além de pedidos com relação à aplicação da pena.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls.05/06, boletim de ocorrência de fls.01/03, termo de depoimento de fls.08/09, termo de declaração de fl.09, termo e interrogatório de fl.10, autos de exibição e apreensão de fl.15, imagens de fls.28 e 30), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada pelos elementos indicados, assim como pela prisão em flagrante e consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

A vítima Mykon de Araújo Santos confirmou que o furto ocorreu, mas não estava presente. Recebeu ligação para comparecer ao local e depois foram para a delegacia. Disse que o local estava fechado com cadeado. Não sabe dizer o horário dos fatos. Falou que as três barras de ferro subtraídas têm valor aproximado de R\$ 200,00 a R\$ 240,00.

A testemunha e policial militar Victor Vidcardi Lopes, contou que em patrulhamento avistaram o acusado em uma bicicleta com 3 barras de ferro. Fizeram abordagem e indagaram-no sobre as barras de ferro, sendo que o réu falou que havia ganhado os objetos. Em continuidade à entrevista, ele acabou por indicar onde havia conseguido as barras. Contataram o proprietário da construção e o acusado acabou por confessar o furto e que trocava por drogas. Já conhecia o réu por outros crimes, salvo engano tráfico de drogas. Disse que não se recorda se o réu foi comunicado de seu direito de ficar em silêncio. Aparentemente o réu estava tranquilo.

Interrogado, o réu confessou os fatos, dizendo que iria vender as barras de ferro para comprar drogas e cigarro.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de furto simples é procedente.

De início, quanto à consumação do furto, assim como para o roubo (súmula 582), o STJ consolidou o entendimento, no sentido da adoção da teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que por breve espaço de tempo. Não há a necessidade de o agente ter a posse mansa e pacífica do objeto para configurar o delito. Foi justamente o que ocorreu nos autos.

Confira-se (AgRg no HC 583297 / SC): "Para a consumação do crime de furto, não se exige a posse mansa, pacífica e desvigiada da res furtiva, sendo reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF e do Superior Tribunal de Justiça - STJ a aplicação da teoria da amotio, que a apenas demanda a inversão da posse do objeto material do crime" (RHC n. 74.846/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 26/05/2017).

Certo que a vítima confirmou a ocorrência do furto, assim como o policial ouvido nesta audiência.

E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

A vítima não demonstrou nenhuma disposição especial para prejudicar o caso, merecendo crédito sua versão.

Por sua vez, o réu confessou os fatos integralmente, dizendo que viu as barras de ferro e delas se apossou sem ingressar na construção.

Quanto ao entorpecimento no momento do fato, anoto que a embriaguez não exclui a imputabilidade, na forma do CP 28, II. Trata-se, ademais, de embriaguez voluntária.

Com relação à alegação de ilicitude da prova, deixo de acolhê-la, porque i) o policial militar disse não se recordar se o réu foi ou não cientificado de seus direitos, não se podendo falar com certeza se houve violação e ii) o réu foi

flagrado em poder das barras de ferro, sendo que, com ou sem sua entrevista, os policiais lograriam obter informações a respeito de sua procedência, notadamente pelas dimensões da cidade de Castilho, características do réu e dos objetos - aplica-se, então, a lógica do CPP 157, § 1º, no que diz respeito à fonte independente para obtenção de outros elementos.

Cabe, ainda, reconhecimento da majorante da prática do crime durante o repouso noturno. Anoto que para a configuração da referida majorante, prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018). Ainda que o crime tenha sido praticado na modalidade simples a majorante é aplicável, afastando-se a aplicação topográfica, pois ao furto qualificado, previsto no § 4º, se reconhece a possibilidade de aplicação do privilégio, previsto no § 2º. A mesma lógica deve ser aplicada ao furto simples (aplicação do parágrafo § 1º ao caput) - AgRg no HC 731807 / SP - 5ª Turma - Julgado em 26/04/2022.

Inviável também se cogitar de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incidência do princípio depende de uma minuciosa análise de requisitos objetivos, relacionados ao fato, e requisitos subjetivos, vinculados ao agente e a vítima.

Por tais motivos, seu cabimento deve ser avaliado com base nas peculiaridades de cada caso concreto, e não no plano meramente abstrato (Nesse sentido: STF: HC/123.108/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.08.2015, noticiado no Informativo 793 e STJ: AgRg no RHC 44.461/RS, rel. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 27.05.2014, noticiado no Informativo 542).

O Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0/SP) idealizou quatro requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, o valor dos danos causados supera os parâmetros normalmente estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para a insignificância (STJ - AgRg no REsp 1744802 MS 2018/0131490-7 e STJ - AgRg no AREsp 946939 MS 2016/0176618-5). Some-se a isso o fato de o réu ser reincidente.

Não obstante, o fato também não pode ser tido como insignificante em razão da presença da majorante, denotando-se a gravidade concreta da ação.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que o rompimento de obstáculo para a prática do crime de furto denota a maior reprovabilidade da conduta dos agentes e afasta, por conseguinte, a incidência do princípio da insignificância. 2. O Tribunal regional, ao apreciar o recurso defensivo, decidiu em consonância com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 746.011/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 23/11/2015)

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o

intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima $1/8$ sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça).

Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto ($1/6$), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de $1/6$ será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Observo que o réu ostenta duas condenações definitivas por tráfico de drogas (fls. 54/56), sendo que uma delas será valorada na primeira fase, e a outra na segunda, como reincidência.

Ressalto que a pena parte do mínimo legal (1 ano) e a este patamar serão somados os montantes das frações encontradas a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a partir da pena mínima.

NÃO SE TRATA DE UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DO TERMO MÉDIO (O QUAL FARIA A PENA-BASE PARTIR DE 2 ANOS E 6 MESES E NÃO DO MÍNIMO), TAMPOUCO DE ERRO ARITMÉTICO.

Trata-se de utilização de distinta base de cálculo para encontro das frações de mudança da pena, utilizando-se o resultado do intervalo entre a pena mínima e máxima, e não a pena mínima, critério este que considera a gravidade do crime de forma global conforme estipulada pelo legislador e mostra-se mais proporcional ao juízo prévio feito pelo parlamento sobre a natureza do crime (caso contrário, crimes com pena mínima igual e pena máxima diversas, como o estupro e o homicídio, o furto qualificado e a corrupção passiva, etc, teriam idêntico apenamento, o que não se mostra de fato adequado, pois o legislador já estabeleceu distinção prévia de gravidade, a ser observada pelo julgador; já crimes com penas mínimas muito elevadas, teriam exasperações exageradas, como a extorsão mediante sequestro com resultado morte, com pena mínima de 24 anos).

De toda forma, destaco novamente que o tópico acima ("critérios para fixação da pena") estabelece as justificativas pelas quais a individualização da pena resta melhor assegurada por esta forma de cálculo, que é diferente do padrão normalmente adotado (mais cômodo para cálculos, mas que desconsidera inúmeros fatores de proporção e postulados a respeito da prevalência dos critérios de lei sobre critérios subjetivos), mas que é referendado por argumentos racionais e também pela jurisprudência do STJ (HC 498586/SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020 e AgRg no REsp 1704633/TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019).

Feito novamente tal esclarecimento, adiciono à pena mínima (de 1 ano) o montante de 4 meses e 15 dias de reclusão, montante equivalente a 1/8 de 3 anos (intervalo de pena estabelecido pelo legislador ao considerar globalmente a gravidade do crime) e estabeleço a pena-base em 1 ano e 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. Na segunda fase, observo que o acusado é reincidente mas confessou o crime, circunstância levada em conta para a formação da convicção sobre a condenação. Na esteira de já consolidada jurisprudência do STJ (HC n. 365.963/SP), neutralizam-se as circunstâncias.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, diante da majorante prevista no art. 155, § 1º, aumento a pena em 1/3.

Sendo assim, a pena fica em 1 ano e 10 meses e 70 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a quantidade de pena e dupla reincidência deve ser

o semiaberto.

Entretanto, por não se tratar de reincidência específica (art. 44, § 3º, do CP) e pela menor gravidade em concreto do fato, entendo viável e recomendável a substituição da pena privativa de liberdade, por reprimenda restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução e 2) obrigação de se submeter a tratamento para drogadição junto ao CAPS-AD, apresentando comprovação de comparecimento nos autos, descontando-se o período que o acusado ficou preso por este feito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO ROBERTO ALEXANDRE DOS SANTOS, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput e § 1º, do Código Penal, à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 70 dias-multa, calculados em seu mínimo legal. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, consistente em: 1) prestação de serviços à comunidade, a critério do juízo da execução, à razão de uma hora de tarefa por dia de pena, descontando-se o período que o acusado ficou preso por este feito e 2) obrigação de se submeter a tratamento para drogadição junto ao CAPS-AD, pelo prazo de 6 meses, apresentando comprovação de comparecimento nos autos.

O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Condene o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade, que fica aqui deferida ante as condições socioeconômicas do acusado. Com o trânsito, i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, ii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado que atuou pelo convênio.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 07 de junho de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)